

[사례형 답안]

1. (20점)

가. 갑과 을의 관할합의의 성질 (7점)

- 관할합의를 함에 있어 전속적 합의인지, 부가적 합의인지 명시적으로 약정한 경우에는 그 합의에 따르나, 합의 내용이 불분명한 경우에는 당사자에게 석명을 구하고, 석명을 통해서도 내용이 불분명한 경우에 어느 것으로 보아야 할지에 관하여 논의가 있음
- 관례는 법정관할법원 가운데 하나로 관할법원을 특정하는 경우에는 전속적 합의로, 법정관할법원 외의 다른 법원을 관할법원으로 하는 경우를 부가적 합의로 봄.
- 사안은 당사자의 합의 내용이 전속적 합의인지, 부가적 합의인지 불분명한 경우이고, 법정관할은 서울중앙지방법원(피고 주소지)과 수원지방법원(지참채무)에 인정됨. 따라서 서울중앙지법으로 정한 관할합의는 법정관할법원 중 하나를 특정한 것으로 전속적 합의에 해당함.
- 따라서 서울중앙지법에만 관할이 인정되며 수원지방법원의 관할은 배제됨.

다. 변론관할의 성립 여부 (5점)

- 변론관할의 의미
- 사안에서 수원지방법원에 변론관할이 생기는지 여부가 문제되나, 피고가 관할위반의 항변을 하면서, 조건적으로 본안에 관한 항변을 하였으므로, 수원지방법원에 변론관할이 성립되지 않음

라. 을의 관할위반주장에 관한 법원의 판단 및 이송신청에 관한 법원의 조치 (8점)

- 따라서 갑이 수원지방법원에 이 사건 소를 제기한 것은 관할권이 없는 법원에 소를 제기한 것으로서 을의 관할위반에 관한 주장은 타당함
- 법원은 서울중앙지방법원에 직권으로 사건을 이송하여야 함
- 소송당사자에게는 관할위반을 이유로 한 이송신청권이 인정되지 않으므로 당사자가 관할위반을 이유로 한 이송신청을 한 경우에도 이는 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없는 것이고 법원은 이러한 이송신청에 대하여는 재판을 할 필요가 없음. 따라서 사안에서 재판부는 을의 이송신청에 대해서는 따로 재판을 할 필요가 없음

2. (20점)

가. 소송대리인이 있는 경우 소송계속 중 당사자 사망의 효력 (10점)

- 소송계속 중 당사자가 사망하면 소송당사자의 지위가 상속인에 당연승계되고 소송절차는

중단됨

- 그러나 소송대리인이 있는 경우 당해 소송대리인이 상속인들 모두를 위한 대리인이 되어 소송수행을 할 수 있으며 소송절차는 중단되지 않음. 이 경우 상속인의 수계 절차 여부와 상관없이 소송대리인이 소송을 수행하며, 상속인들 모두에 대하여 판결의 효력이 미침
- 사안에서 A변호사가 있으므로 1심 소송절차는 중단되지 않고, A변호사는 병과 정의 대리인으로서 소송수행할 수 있으며, 수계절차를 밟지 않은 정에게도 1심 판결의 효력이 미침

나. A변호사의 항소제기가 정에게 효력이 미치는지 (10점)

- 심급대리의 원칙상 1심 판결정본 송달로 소송대리인의 소송수행권이 소멸하므로 위 시점에 소송이 중단되나, 소송대리인에게 항소제기의 특별수권 있는 경우에는 항소기간 도과시 또는 항소 제기시까지 소송대리인의 소송수행권이 존속하므로 위 시점에 소송이 중단됨
- 사안에서 을의 소송대리인으로 A변호사가 선임되어 있고 A변호사는 항소제기의 특별수권을 받았는바, 항소제기의 특별수권 있는 A변호사가 항소한 것은 상속인 전원을 위하여 항소한 것이 되므로(항소인 표시에 정이 누락되어도 마찬가지임), A변호사의 항소는 정에게도 효력이 있음(대판 2007다22859)

3. (20점)

가. 채권자대위소송의 법적 성격 (5점)

- 채권자 대위소송의 법적성격을 법정소송담당이라고 보는 판례에 의할 경우, 피보전권리는 당사자적격의 문제로 귀결되고, 소송물은 피대위권리임.

나. 채권자대위소송에서 피보전채권 흠결의 소송법적 효과 (10점)

- 채권자대위소송에서 피보전권리에 관하여 피보전채권의 존재 및 이행기 도래, 채무자의 권리 불행사, 보전의 필요성 등의 요건을 갖추어야 하는바, 이러한 요건 흠결시에는 당사자적격 흠결로 귀결됨
- 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 이행을 구하는 소를 제기하였으나 패소확정판결을 받았다면 그 확정판결의 기판력으로 말미암아 채무자에게 동일한 원인으로 동일한 청구를 할 수 없으므로, 그러한 권리를 보전하기 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 행사하는 채권자대위소송은 보전의 필요성이 없어 당사자적격 흠결로 부적법

라. 사안의 해결 (5점)

- 사안에서 갑이 병,정에 대한 매매대금반환청구소송에서 패소하였고, 당사자가 이에 항소하지 않아 위 판결은 확정되었음. 그 후에 갑이 다시 매매대금반환채권을 피보전권리로 하여 병,

정을 대위하여 무에게 부당이득반환청구소송을 제기하였는바, 위 채권자대위소송은 피보전채권에 관한 갑 패소의 확정판결이 존재하므로 보전의 필요성이 없어 당사자적격 흠결로 부적법함.

- 법원은 소각하 판결을 선고하여야 함.

4. (20점)

가. (10점)

- 법률요건분류설에 따라 불법행위에서 가해행위, 손해발생, 가해자의 고의 과실, 가해행위와 손해의 인과관계는 원고(피해자)인 을에게 입증책임이 있다.
- 그런데 인과관계 및 가해자의 고의 과실과 관련하여, 고도의 개연성이 있는 경험법칙을 이용하여 간접사실로부터 주요사실을 추정할 수 있는바, 이를 일응의 추정(정형적 사상경과를 이용한 추정)이라 한다.
- 을은 갑의 차량이 보행신호 중 횡단보도에 진입한 사실(간접사실)을 입증하여, 일응의 추정에 따라 요건사실인 인과관계와 가해자의 과실을 입증할 수 있다.
- 이때 가해자는 간접반증을 통하여, 즉 그 간접사실과 양립하는 별개의 사실(갑 승용차의 횡단보도 진입이 뒷차에 의한 충격의 결과라는 사실)을 입증함으로써 일응의 추정을 복멸할 수 있다.

나.(10점)

사안에서, 법원이 '갑의 승용차가 파란색 보행등이 켜진 횡단보도 안에 진입한 사실'에 대해 심증을 형성하였다면, 위 간접사실을 기초로 한 일응의 추정에 따라 '인과관계'와 '갑의 과실'이 입증된 것으로 볼 수 있다.

따라서 병회사는 '갑 승용차의 횡단보도 진입이 뒷차에 의한 충격의 결과'라는 별개의 간접사실에 대하여 입증하여야 하는데 이를 입증하지 못한 것이므로, 일응의 추정의 복멸에 성공하지 못한 것이다.

- 따라서 법원은 일응의 추정에 따라 (인과관계 및) 갑의 과실을 인정할 수 있다.